

刑事訴訟法
No247

H18-33

(配点: 3)

月 日

月 日

次の教授と学生AないしCの【会話】は、違法収集証拠の証拠能力についての最高裁判所の判例に関するものである。①から⑥までの()内に入る適切な語句を後記の【語句群】から一つずつ選んで入れた場合、①、③、④及び⑥の()内に入る語句の組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。なお、同じ語句を2回以上用いてもよい。

【会 話】

教 授 最高裁判所は、昭和53年9月7日の第一小法廷判決で、捜査に違法があった場合の証拠能力の可否について、「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」と判示していて、「違法の重大性」と「排除相当性」という二つの要件を示していると思われるが、両者の要件の関係についてどう考えるべきか、みんなで議論してみよう。

学生A 両者の要件がそろって初めて証拠が排除されるとする説、いずれか一方の要件があれば証拠が排除されるとする説、結局は「違法の重大性」が要件であるとする説などがあります。

学生B この判決を素直に読めば、両者の要件がどちらも必要だ、つまり両者を言わば「かつ」の関係にあるものとして考えるのが最高裁判所の立場になるのではないのでしょうか。

学生C でも、その判決は、事案の結論として証拠能力を肯定するに当たって、「本件証拠物の押収手続の違法は必ずしも重大であるとはいえないのであり、これを被告人の罪証に供することが、違法な捜査の抑制の見地に立ってみても相当でないと認めがたいから、本件証拠物の証拠能力はこれを肯定すべきである。」と判示していて、両者の要件を併せて検討しています。これに注目すれば、最高裁判所は、例えば「違法の重大性」がなくても「排除相当性」が認められるので証拠能力を否定すべき場合があると考えている、つまり、両者の要件を(①)の関係にあると考えていると解釈の方が説得力があると思います。

教 授 この判決は、念のため、あるいは、確認的に、「違法の重大性」も「排除相当性」もない事案だと述べたにすぎないと考えることもできるのではないかね。

学生C そもそも違法収集証拠排除法則の根拠であると言われている「司法の廉潔性」と「違法捜査の抑止」という別個独立の根拠が、それぞれ「違法の重大性」と「排除相当性」の要件に反映していると考えられ、両者は、(②)の関係にあると考えるべきだと思います。

教 授 ところで、平成15年2月14日最高裁判所第二小法廷判決は、「本件逮捕には、逮捕時に逮捕状の呈示がなく、逮捕状の緊急執行もされていないという手続的な違法があるが、それにとどまらず、警察官は、その手続的な違法を糊塗するため、(中略)公判廷において事実と反する証言をしているのであって、本件の経緯全体を通して表れたこのような警察官の態度を経合的に考慮すれば、本件逮捕手続の違法の程度は、令状主義の精神を潜脱し、没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないものといわざるを得ない。そして、このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは、将来における違法捜査抑制の見地からも相当でないと認められるから、その証拠能力を否定すべきである。」と判示していて、公判廷で偽証したことを(③)の要件の中で検討しているよね。

学生A. 捜査行為の違法性判断は(④)に存在した事情を基礎として考えるのが一般的な判断手法です。違法な逮捕後に示された警察官の法軽視の態度からさかのぼって逮捕手続における(⑤)を認めるのはちょっと無理ではないでしょうか。

学生C. でも、捜査官の捜査行為時における主観的意図を推認する限りで、公判廷で捜査官が虚偽の証言をしたという事情を(⑥)の判断要素の一つにすることは可能だと思います。

【語句群】

- | | | | |
|-----------|------------|---------|-----------|
| a. 排除相当性 | b. 証言当時 | c. 「又は」 | d. 軽微な違法性 |
| e. 行為当時 | f. 違法捜査の抑止 | g. 裁判当時 | h. 「かつ」 |
| i. 違法の重大性 | j. 司法の廉潔性 | | |

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. ①c③i④e⑥i | 2. ①c③a④e⑥i | 3. ①c③d④b⑥a |
| 4. ①h③j④g⑥j | 5. ①h③i④g⑥i | |

() には順に、① = c、② = c、③ = i、④ = e、⑤ = i、⑥ = i と入り、したがって、正解は肢 1 となる。

完成全文

教 授. 最高裁判所は、昭和 53 年 9 月 7 日の第一小法廷判決で、捜査に違法があった場合の証拠能力の肯否について、「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でない」と認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」と判示していて、「違法の重大性」と「排除相当性」という二つの要件を示していると思われるが、両者の要件の関係についてどう考えるべきか、みんなで議論してみよう。

学生 A. 両者の要件がそろって初めて証拠が排除されるとする説、いずれか一方の要件があれば証拠が排除されるとする説、結局は「違法の重大性」が要件であるとする説などがあります。

学生 B. この判決を素直に読めば、両者の要件がどちらも必要だ、つまり両者を言わば「かつ」の関係にあるものとして考えるのが最高裁判所の立場になるのではないのでしょうか。

学生 C. でも、その判決は、事案の結論として証拠能力を肯定するに当たって、「本件証拠物の押収手続の違法は必ずしも重大であるとはいえないのであり、これを被告人の罪証に供することが、違法な捜査の抑制の見地に立ってみても相当でない」とは認めたいから、本件証拠物の証拠能力はこれを肯定すべきである。」と判示していて、両者の要件を併せて検討しています。これに注目すれば、最高裁判所は、例えば「違法の重大性」がなくても「排除相当性」が認められるので証拠能力を否定すべき場合があると考えている、つまり、両者の要件を (① c、又は) の関係にあると考えていると解説する方が説得力があると思います。

教 授. この判決は、念のため、あるいは、確認的に、「違法の重大性」も「排除相当性」もない事案だと述べたにすぎないと考えることもできるのではないかね。

学生 C. そもそも違法収集証拠排除法則の根拠であると言われている「司法の廉潔性」と「違法捜査の抑止」という別個独立の根拠が、それぞれ「違法の重大性」と「排除相当性」の要件に反映していると考えられ、両者は、(② c、又は) の関係にあると考えるべきだと思います。

教 授. ところで、平成 15 年 2 月 14 日最高裁判所第二小法廷判決は、「本件逮捕には、逮捕時に逮捕状の呈示がなく、逮捕状の緊急執行もされていないという手続的な違法があるが、それにとどまらず、警察官は、その手続的な違法を糊塗するため、(中略) 公判廷において事実と反する証言をしているのであって、本件の経緯全体を通して表れたこのような警察官の態度を総合的に考慮すれば、本件逮捕手続の違法の程度は、令状主義の精神を潜脱し、没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないものといわざるを得ない。そして、このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは、将来における違法捜査抑制の見地からも相当でない」と認められるから、その証拠能力を否定すべきである。」と判示していて、公判廷で偽証したことを (③ i、違法の重大性) の要件の中で検討しているよね。

学生 A. 捜査行為の違法性判断は (④ e、行為当時) に存在した事情を基礎として考えるのが一般的な判断手法です。違法な逮捕後に示された警察官の法軽視の態度からさかのぼって逮捕手続における (⑤ i、違法の重大性) を認めるのはちょっと無理ではないでしょうか。

学生 C. でも、捜査官の捜査行為時における主観的意図を推認する限りで、公判廷で捜査官が虚偽の証言をしたという事情を (⑥ i、違法の重大性) の判断要素の一つにすることは可能だと思います。

【穴埋めについて】

① c

「違法の重大性」と「排除相当性」の要件の関係については、両方の要件を満たしたときにはじめて証拠が排除されるとする重畳説（i）、いずれか一方の要件が備われば証拠が排除されるとする競合説（ii）、違法の重大性のみが排除の要件だとする説（iii）がある。学生Cは第一発言において、学生Bの発言に「でも」と続けており、（i）説を採る学生Bとは異なる説を採っていることが分かる。さらに学生Cは第一発言において、最高裁判所は「違法の重大性」がなくても証拠能力を否定すべき場合があると考えていると述べているので、（iii）説を採っていないことが分かる。よって、学生Cは（ii）説を採っていることが分かる。したがって、①には「c. 『又は』」が入る。

② c

学生Cは違法収集証拠排除法則の根拠として、「司法の廉潔性」、「違法捜査の抑止」を挙げており、両者を別個独立の根拠とした上で、それぞれ「違法の重大性」、「排除相当性」に反映しているとする。このように解するならば、「違法の重大性」と「排除相当性」の要件は並列の関係にあることになる。したがって、②には「c. 『又は』」が入る。

③ i

③は、平成15年2月14日最高裁判所第二小法廷判決が、公判廷で偽証したことを「違法の重大性」及び「排除相当性」のいずれで検討しているかを問うものである。そこで教授の発言に引用されている前記平成15年判決を読んでみると、同判決は、「警察官は」「公判廷において事実と反する証言をしているのであって、」「このような警察官の態度を総合的に考慮すれば、本件逮捕手続の違法の程度は」「重大なものであると評価されてもやむを得ない」としていることが分かる。このように同判決は、公判廷で偽証した違法は重大であるとしているので、公判廷で偽証したことは、「違法の重大性」の要件で検討されているといえる。したがって、③には「i. 違法の重大性」が入る。

④ e

違法収集証拠排除法則とは、証拠の収集手続が違法であった場合に、その証拠能力を否定し、事実認定の資料から排除する原則である。違法収集証拠排除法則が証拠の収集手続に違法があった場合の法則である以上、違法性判断は証拠の収集手続時、すなわち捜査の行為当時に存在した事情を基礎に考えることになる。したがって、④には「e. 行為当時」が入る。

⑤ i

⑤を含む学生Aの第二発言は、違法性判断は行為当時に存在した事情を基礎とするのが一般的としているので、違法性判断の基準時について述べているものといえる。そしてこの発言が、公判廷で偽証したという捜査行為後の事情を「違法の重大性」の中で検討した平成15年判決に対する批判としてなされていることからすれば、学生Aは違法な逮捕後に示された警察官の法軽視の態度については「違法の重大性」の要件で検討すべきでないとの立場を採っていることが分かる。したがって、⑤には「i. 違法の重大性」が入る。

⑥ i

ある証拠の収集手続が終わった後に違法行為があったという場合（いわゆる「後の違法」）、この違法行為は過去の行為である証拠収集手続に因果的影響を及ぼすことはないので、違法収集証拠排除法則の適用に当たって考慮すべきでないとも思える。平成15年判決における公判廷での偽証行為も、「後の違法」であることからすれば、排除法則の適用に当たって考慮すべきではないという結論になりそうである。しかし、「後の違法」は警察官の法軽視の態度の表れであり、それが逮捕の際の令状主義の精神を没却させる態度を推知させると解すれば、逮捕手続の違法という「前の違法」の重大性

を強める事情として、公判廷での偽証という「後の違法」を考慮することも可能であると思われる。したがって、⑥には「i. 違法の重大性」が入る。

なお、⑥を含む学生Cの第三発言は、違法な逮捕後に示された警察官の法軽視の態度からさかのぼって逮捕手続における違法の重大性を認めるのは無理ではないかという学生Aの意見に対する反論としてなされていることから、⑥には「i. 違法の重大性」が入る。